

1501584-09.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501584-09.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501584-09.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169341/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 25704360 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2169341 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ALMEIDA DE REZENDE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

GABRIEL ALMEIDA DE REZENDE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 19h45min, na Rua Lesta, nº 23, Vila Rio de Janeiro, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 154,8g de Tetrahydrocannabinol-THC, vulgarmente conhecida como maconha, distribuídos em 75 invólucros, 21,3g de Tetrahydrocannabinol-THC, conhecida como maconha, distribuídos em 10 invólucros, 265,7g de cocaína distribuídos em 350 invólucros e 17,6g de cocaína distribuídos em 20 invólucros, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme boletim de ocorrência a fls. 5/8, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo de constatação de fls. 14/17) (fls. 65/66).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/59).

Devidamente notificado (fls. 156/157), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas (fls. 78/82).

A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2022 (fls. 98/102).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação provisória (fls. 14/17), laudo de exame químico-toxicológico - laudo definitivo (fls. 138/140), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), laudo pericial de exame de peça (fls. 141/143), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão, vejamos.

O acusado GABRIEL ALMEIDA DE REZENDE, em solo policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 04). Em juízo, confessou parcialmente os fatos a ele imputados. Disse que já foi preso e processado por tráfico. Estava cumprindo pena em regime aberto. Também teve passagens na Vara da Infância por roubo. Sobre os fatos, disse que estava saindo da viela quando avistou as viaturas das ROCAM. Foi abordado e correu. Admitiu estar trazendo consigo 20 pinos de cocaína e 10 porções de maconha, que seriam destinadas ao tráfico. Afirmou que o restante da droga não lhe pertencia.

Os policiais militares ISAIAS IRINEU DIAS e RAPHAEL DA MOTA BARRETO ALEXANDRONI, em solo policial, em depoimentos semelhantes, narraram que durante patrulhamento pela Rua Lesta, 28, viram 3 homens conversando. Decidiram pela abordagem porque ali é ponto de tráfico de drogas. O indiciado foi detido e os outros 2 conseguiram fugir. Feita busca pessoal no indiciado, foi achado no bolso da bermuda que ele trajava: 20 pinos contendo pó branco parecendo ser cocaína, 10 porções de erva verde parecendo ser maconha e R\$ 197,05 em espécie. Foi feita uma varredura pela mesma via pública e, cerca de 10m de onde estavam, exatamente dentro de uma bolsa que estava na calçada, localizaram mais 350 pinos de pó branco parecendo ser cocaína e 75 porções de erva verde parecendo ser maconha. O indiciado confessou abastecer o tráfico de drogas ali na região do Morro do Amor, sem tecer maiores detalhes. Afirmou que toda a abordagem ao indiciado e a localização das substâncias foram gravadas pela body cam. Diante dos fatos, conduziram a ocorrência para este DP (fls. 02/03).

Em juízo, o policial militar ISAIAS IRINEU DIAS, declarou que estava em patrulhamento de motocicleta em local já é conhecido como ponto de tráfico, quando avistou o réu, o qual estava em companhia de mais dois indivíduos. Dois saíram correndo. Ficou apenas o acusado. Afirmou que o réu também tentou fugir, mas foi abordado bem na entrada da comunidade. Encontraram alguns eppendorfs com ele. Posteriormente, em buscas pelo local, encontraram mais drogas fracionadas. Disse que o réu estava próximo do local onde encontraram as drogas. No momento da abordagem, apenas conseguiram ver a face do rapaz. Ele estava com a face suada, como se tivesse trabalhando. As pochetes com drogas estavam enterradas. Disse que os três rapazes estavam juntos, dois correram e o réu não conseguiu correr na hora. Ele correu uns 10 metros. Com ele, encontraram pó branco e uma erva esverdeada. Encontraram dinheiro trocado com ele. Indagado, ele disse que já tinha sido preso ali. Informou que um carro passava no local e abastecia a comunidade com as drogas. Ele era responsável por fracionar as drogas para a venda e abastecer a comunidade. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar RAPHAEL DA MOTA BARRETO

ALEXANDRONI, o qual, em juízo, relatou que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico. O acusado tentou se evadir para dentro da comunidade. Ele dispensou sacolas de entorpecentes. Inicialmente, quando avistado, ele estava saindo da Av. Salgado Filho. Estava sozinho. Ele deu a volta, na segunda oportunidade, havia mais pessoas. Ele dispensou drogas atrás de um veículo. Era cocaína e maconha. Isaías correu, conseguiu segurar ele. Não se recorda se foi ele ou o colega que revistou o acusado. Havia algumas pessoas distantes dele.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

“Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Pois bem, diante da confissão do acusado, acrescida dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares ouvidos na fase policial e em juízo, além das circunstâncias da prisão do réu, é de se reconhecer que restou demonstrado, à sociedade, que GABRIEL trazia consigo os entorpecentes apreendidos, para entrega ao consumo de terceiros, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória. Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário. Ademais, ainda que não se saiba com segurança se o restante da droga apreendida também pertencia ao réu, certo é que com ele foram apreendidas porções de cocaína e maconha, conforme confirmado pelas testemunhas e admitido pelo próprio réu, o que seria suficiente para a configuração do delito.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias se destinavam ao tráfico, diante da

natureza, variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos em seu poder (21,3g de Tetrahydrocannabinol-THC, conhecida como maconha, distribuídos em 10 invólucros e 17,6g de cocaína distribuídos em 20 invólucros), da forma como estavam embalados e separados, em pequenas porções prontas para a comercialização, além da quantia em dinheiro e das circunstâncias em que se deu a prisão do denunciado, em local conhecido como ponto de venda de drogas, fora o fato do próprio acusado ter admitido tal destino.

Vale ressaltar que o fato do réu não estar vendendo entorpecentes no momento da abordagem policial, não desconfigura o delito de tráfico de drogas, eis que o tipo penal é de ação múltipla, configurando o crime aquele que pratica qualquer uma das condutas ali descritas, entre as quais a de trazer consigo o entorpecente destinado ao fornecimento a terceiro, conduta esta imputada ao acusado cuja prova restou incontroversa.

Sobre o assunto abarca a jurisprudência:

“É certo que a comprovação exigida pelos delitos previstos nos artigos 33, “caput” e 28, da Lei de Drogas, não é de fácil constatação, sendo certo que, tal análise deve ter por base as provas extraídas da própria situação fática. Desse modo, para que não se cometam injustiças confundindo usuários com traficantes, para configuração das condutas criminosas previstas na Lei em comento, deverão ser analisadas a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do acusado. Também deve se levar em consideração a forma de acondicionamento da droga”. (Apelação nº 0054000-21.2008.8.26.0114, Rel. Des. Borges Pereira, 16ª Câmara. Direito Criminal).

Em outras palavras, traficante “não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas” (RF 320/237).

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a

prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: "considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente." (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado GABRIEL, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, levando em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo ainda, nessa primeira fase, que o réu teria praticado o presente crime enquanto cumpria pena em regime aberto, em razão da prática de outro delito de tráfico de drogas (processo n.º 0002266-14.2017.8.26.0535, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 43/44), o que demonstra maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta, evidenciando ainda descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado. Cumpre salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte, até porque é possível que o réu reincidente pratique novo crime quando já extinta sua pena pelo crime anterior, conduta que embora inaceitável, é menos reprovável do que aquele que também reincidente pratica no vo crime, quando em cumprimento da pena ou no gozo do livramento condicional pelo crime anterior. O aumento da pena, neste momento, nada mais é do que o cumprimento do princípio da individualização das penas, punindo com maior rigor aquele que tem a conduta mais reprovável. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Assim, diante das circunstâncias judiciais apontadas, na primeira etapa, entendo que a pena-base deverá ser acrescida de 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)

dias-multa.

Ressalto que a quantidade de entorpecente apreendida em poder do réu (21,3g de Tetrahydrocannabinol-THC e 17,6g de cocaína), não se mostra excessiva a justificar aumento da pena-base, isto porque embora o total do entorpecente apreendido na ocorrência seja elevando, não restou evidenciado de forma segura, como acima apontado, que o réu também era o responsável pela droga escondida, daí porque sua pena está sendo valorada levando em conta apenas os entorpecentes encontrados em seu poder.

Na segunda fase da pena, presente a atenuante da confissão. Presente, também, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de tráfico de drogas (processo n.º 0002266-14.2017.8.26.0535, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0004804-58.2018.8.26.0041, da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 43/44 e F.A. de fls. 45/47) sendo, portanto, reincidente específico. Assim, compenso a atenuante com a agravante e mantenho a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem observadas, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Observo que, em face da reincidência, que no presente caso ainda é específica, específica, fica afastada a causa de diminuição de pena tipificada no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06. Não há que se falar em bis in idem mormente porque, para incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o réu seja primário, o que não se verifica no caso em análise.

Esse é o forte posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM BASE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE DOIS DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTA QUE EXTRAPOLOU À INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA E TERCEIRA FASES QUE NÃO ENSEJA BIS IN IDEM. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO DETERMINADO EM FUNÇÃO DO MONTANTE DA REPRIMENDA IMPOSTA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - A reincidência do paciente constitui óbice suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista não estar preenchido o requisito legal da primariedade. Precedentes. - Ademais, a orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...)” (AgRg no HC 630.337/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (Grifei);

“(...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de

um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...) 8. Habeas corpus não conhecido". (STJ HC 427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.03.2018, DJe 20.03.2018 g.n.).

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288). Diante da quantidade da pena imposta e reincidência específica do agente incabível a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em se tratando de delito equiparado a hediondo, o regime inicial para o cumprimento de pena para o acusado é o FECHADO, justificável não só ante a latente gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas como também pelo fato de os demais regimes não se mostrarem adequados para a ressocialização do réu, além de serem incompatíveis com sua reincidência específica, demonstrando dedicação à prática delitiva, evidenciando que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito.

Deveras, não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito as seguintes jurisprudências:

"TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. "Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado". RECURSO NÃO PROVIDO." (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelos réu, o regime de pena imposto por lei, o fato do acusado ser reincidente específico e ter praticado o delito sob julgamento enquanto cumpria pena em regime aberto por outro crime semelhante, além de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade, afora tratar-se de imposição legal, nos moldes do artigo 44 da Lei nº. 11.343/06. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, diante das condições subjetivas e a quantidade de pena aplicada ao acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do

delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR GABRIEL ALMEIDA DE REZENDE, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Considerando a relação do dinheiro apreendido nos autos (auto de exibição/apreensão de fls. 10/11) com o tráfico ilícito de entorpecentes, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Sobre Drogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 29 de agosto de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA